

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5553/2542

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด
(มหาชน)

นายเสริมศักดิ์ ภิญโญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 728, มาตรา 735

ในกรณีเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนองประสงค์จะฟ้องบังคับจำนอง กฎหมายบังคับให้เจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้จำนองซึ่งเป็นลูกหนี้ และต้องกำหนดเวลาอันสมควรเพื่อให้โอกาสผู้จำนองชำระหนี้จำนอง การบอกกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขที่ผู้รับจำนองจะต้องกระทำให้ถูกต้องก่อน จึงจะฟ้องบังคับจำนองได้ การบอกกล่าวดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาที่ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนา ซึ่งกฎหมายกำหนดคือผู้จำนอง ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ส. ผู้จำนองถึงแก่กรรมก่อนโจทก์มีหนังสือบอกกล่าว แม้จะมีผู้อื่นรับหนังสือนั้นไว้ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ ส. ผู้จำนองถึงแก่กรรม มรดกรวมตลอดถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบตกทอดแก่ทายาทของ ส. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599, 1600 ถ้ามีผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองแล้ว หากโจทก์ประสงค์จะบังคับจำนอง ต้องมีเจตนาบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้า 1 เดือนก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 735 ถ้ายังไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง แต่ ส. ผู้จำนองมีทายาทหรือผู้จัดการมรดก โจทก์ต้องบอกกล่าวเป็นเจตนาหรือหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน แก่บุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นเสมือนผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง จึงจะฟ้องบังคับจำนองได้ เมื่อโจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทผู้จำนองก่อนฟ้อง และการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,028,850.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของเงินต้น 496,773.97 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์จำนองนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ ถ้าไม่พอชำระ ให้ยึดหรือบังคับคดีเอากับทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองและทรัพย์สินในกองมรดกของนางสุณาผู้ตายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,028,850.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 496,773.97 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ จำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตน

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์จำนวน 500,000 บาท ยินยอมให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยได้ ตกลง

ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน กำหนดชำระเงินคืนเมื่อโจทก์ทวงถาม มีนางสุณา ไชยแก้ว ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 44107 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต่อโจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้ โดยมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองว่าหากบังคับจำนอง เอาทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ นางสุณายอมใช้เงินที่ขาด นั้นจนครบหลังจากทำสัญญา จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินแก่โจทก์เพียง 2 ครั้ง โดยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 จำนวน 20,000 บาท วันที่ 31 กรกฎาคม 2536 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังคงค้างชำระหนี้โจทก์เป็นต้นเงิน 496,773.97 บาท และดอกเบี้ย 65,900.47 บาท โจทก์จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือ ทวงถามไปยังจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ชำระหนี้และบอกกล่าวบังคับจำนองแก่นางสุณา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539 แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และนางสุณาไม่ชำระหนี้ ต่อมา วันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โจทก์จึงทราบว่านางสุณาถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2539 จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและทายาทมีสิทธิรับ มรดกของนางสุณา โจทก์จึงฟ้องบังคับจำนองเอาแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ศาลชั้นต้น วินิจฉัยว่าโจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองหลังจากนางสุณาถึงแก่กรรมแล้ว ถือว่าโจทก์ ยังมีได้บอกกล่าวบังคับจำนอง จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาข้อแรกว่า โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองไปยังนางสุณา ลูกหนี้ผู้จำนองในขณะที่โจทก์ไม่ทราบว่านางสุณาถึงแก่กรรมแล้ว ปรากฏว่ามีผู้รับ หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองแทนผู้ตาย จึงถือได้ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวบังคับจำนอง ไปยังลูกหนี้ผู้จำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 แล้ว พิเคราะห์แล้วมาตรา 728 บัญญัติว่าเมื่อจะบังคับจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีเจตนา ยอมรับบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งกำหนดให้ในคำ บอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้อง คดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ให้เห็น

ว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับจำนองประสงค์จะฟ้องบังคับจำนอง กฎหมายบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้จำนองซึ่งเป็นลูกหนี้ ในคำบอกกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องกำหนดเวลาให้ผู้จำนองชำระหนี้จำนอง และกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องเป็นกำหนดเวลาอันสมควรด้วยทั้งนี้เพื่อให้โอกาสผู้จำนองชำระหนี้จำนอง ทำให้ไม่ต้องถูกฟ้องให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองไปขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้การบอกกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจำนองจะต้องกระทำให้ถูกต้องก่อนจึงจะฟ้องบังคับจำนองได้ การบอกกล่าวดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาที่จะต้องมีการแสดงเจตนา ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าคือผู้จำนองเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางสุณาผู้จำนองถึงแก่กรรมก่อนโจทก์มีหนังสือบอกกล่าว แม้จะมีผู้อื่นรับหนังสือนั้นไว้ ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองที่ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์อุทธรณ์ข้อหลังว่า ในกรณีที่ลูกหนี้ผู้จำนองถึงแก่กรรมโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับจำนองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวบังคับจำนองหรือถ้าจะต้องบอกกล่าวบังคับจำนองการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองแล้ว เห็นว่า เมื่อนางสุณาผู้จำนองถึงแก่กรรม มรดกของนางสุณาซึ่งรวมตลอดถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของนางสุนาย่อมตกทอดแก่ทายาทของนางสุณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599, 1600 ถ้ามีผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองแล้ว โจทก์ประสงค์จะบังคับจำนองโจทก์ต้องมีเจตนาบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้า 1 เดือนก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 735 ถ้ายังไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง แต่นางสุณาผู้จำนองมีทายาทหรือผู้จัดการมรดก โจทก์ต้องบอกกล่าวแก่บุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นเสมือนผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง การบอกกล่าวนี้กฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นจดหมายหรือหนังสือ และต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โจทก์จึงจะฟ้องบังคับจำนองได้ โจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทของผู้จำนองก่อนฟ้อง และการที่โจทก์ฟ้องจำเลย

ที่ 3 และที่ 4 เป็นคดีนี้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองตามกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ โจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปัญญา ถนอมรอด-ระพินทร บรรจงศิลป-วิรัช ลัมวิชัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบังคับจำนอง ผู้รับจำนองจะต้องฟ้องและมีการบอกกล่าวบังคับจำนองก่อนเสมอ มิฉะนั้นจะไม่มีอำนาจฟ้อง การบอกกล่าวบังคับจำนองมีสองกรณีด้วยกัน ได้แก่ การบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้จำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 728 กับการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ผู้รับโอนซึ่งทรัพย์สินจำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 735 ทั้งสองกรณีมีข้อพิจารณา ดังนี้ ประการแรก วิธีการบอกกล่าว ทั้งสองกรณีกฎหมายใช้คำว่าต้องมีจดหมายบอกกล่าว หมายความว่าต้องทำเป็นหนังสือจะบอกกล่าวด้วยวาจาไม่ได้ การทำหนังสือไม่มีแบบ เพียงแต่เขียนข้อความถึงผู้จำนองหรือผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองแล้วแต่กรณีให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2507 หมายความว่าเขียนข้อความลงในด้านหลังนามบัตรแจ้งให้ผู้จำนองนำเงินและดอกเบี้ยชำระภายใน

กำหนด 10 วัน ถือได้ว่าเป็นจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองตาม มาตรา 728 แล้ว
ประการที่สอง ระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 728 บัญญัติว่า ภายในเวลาอันสมควร กรณีเพียงใดจะถือว่าใน
เวลาอันสมควรคงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนหนี้และพฤติการณ์ระหว่าง
คู่กรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 251/2523 โจทก์เคยทวงหนี้ด้วยวาจา
หลายครั้ง แต่จำเลย ไม่ชำระ การที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้
1,350,000 บาท กับดอกเบี้ยภายใน 15 วัน ถือว่าเป็นเวลาอันสมควร คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 2274/2523 โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้ 100,000 บาท กับ
ดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับแต่วันรับหนังสือ จำเลยไม่ชำระโจทก์จึงฟ้องหลังจาก
จำเลยรับหนังสือ 27 วัน ประกอบกับจำเลยผิดนัดชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาพิเศษแล้ว
ถือได้ว่าบอกกล่าวในเวลาอันสมควรแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2220/2535 การ
บอกกล่าวบังคับจำนองกำหนดเวลาให้ชำระหนี้ภายในกำหนด 30 วัน เป็นเวลาอัน
สมควร ถ้าหนังสือบอกกล่าวมิได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ จะถือว่าการบอกกล่าวไม่
ชอบ เช่นในหนังสือบอกกล่าวกำหนดว่าให้จำเลยชำระเงินและไถ่ถอนจำนองเสียใน
เร็ววันที่สุดเห็นได้ว่า ไม่ได้กำหนดให้ไถ่ถอนเมื่อใด เอาความแน่นอนในการที่จะ
พิจารณาว่าภายในเวลาอันสมควรหรือไม่ไม่ได้ จึงเป็นการบอกกล่าวที่ไม่ชอบ (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1608/2506(ประชุมใหญ่)) ส่วนการกำหนดเวลาในหนังสือบอก
กล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 735 นั้น ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า
ต้องล่วงหน้า 1 เดือน จึงจะฟ้องบังคับจำนองได้ดังนั้น ในกรณีนี้หากกำหนดเวลาใน
หนังสือบอกกล่าวน้อยกว่า 1 เดือน ถือว่าการบอกกล่าวไม่ชอบ ประการสุดท้าย จะ
ต้องบอกกล่าวไปยังบุคคลใดบ้าง จะแยกพิจารณาดังนี้ (1) ในกรณีผู้จำนองยังมีชีวิต
อยู่และทรัพย์สินที่จำนองยังไม่ได้โอนให้แก่บุคคลอื่นต้องบอกกล่าวแก่ผู้จำนองตาม
มาตรา 728 เท่านั้น จะบอกกล่าวแก่บุคคลอื่นไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
750/2504 สามีมอบอำนาจให้ภริยาไปทำสัญญาจำนองต่อมาเจ้าหนี้จะบังคับจำนองจึง

ได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่ภริยา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ภริยาใช้ไม่ได้ เพราะเจ้าของทรัพย์สินคือผู้จำนองก็คือสามีเมื่อไม่มีการบอกกล่าวแก่สามี จึงพิพากษายกฟ้อง (2) ในกรณีที่ทรัพย์ที่จำนองได้มีการโอนไปให้แก่บุคคลอื่นแล้ว ผู้รับจำนองจะต้องบอกกล่าวไปยังผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองตามมาตรา 735 (3) ในกรณีที่ผู้จำนองถึงแก่กรรมไปก่อนจะฟ้องบังคับจำนองโดยที่ยังไม่มีการโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองให้แก่บุคคลใด ผู้รับจำนองจะต้องบอกกล่าวแก่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้จำนอง ซึ่งตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วางหลักไว้ว่า บุคคลดังกล่าวเป็นเสมือนผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนอง ดังนั้นจึงต้องบอกกล่าวภายใต้เงื่อนไขตามมาตรา 735 เมื่อปรากฏว่าโจทก์มิได้มีการบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นทายาทของนางส. ผู้จำนองก่อนฟ้อง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องบังคับจำนอง และการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 และที่ 4 ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองตามกฎหมาย จากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีข้อน่าคิดต่อไปว่า ถ้าหากว่าผู้รับจำนองได้บอกกล่าวแก่ผู้จำนองโดยชอบแล้วตามมาตรา 728 ต่อมาผู้จำนองถึงแก่กรรมก่อนมีการฟ้องบังคับจำนอง ผู้รับจำนองจึงต้องฟ้องทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้จำนอง ในกรณีเช่นว่านี้ผู้หมายเหตุเห็นว่า ผู้รับจำนองจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 735 ก่อนจึงจะฟ้องบังคับจำนองได้ กล่าวคือต้องบอกกล่าวบังคับจำนองแก่ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้จำนองอีกครั้งหนึ่ง แม้จะมีการบอกกล่าวแก่ผู้จำนองโดยชอบก็ตาม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมิใช่เจ้าของทรัพย์สินขณะจำนองจึงไม่เป็นผู้จำนองตามมาตรา 705 แต่เป็นเพียงเสมือนผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนองเท่านั้น ฎีกาฉบับนี้พิชฌัญญุตาธรรม